

0001545-13.2017.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... inviável a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº11.343/06

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001545-13.2017.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001545-13.2017.8.26.0616 2017/001634

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2642/2017 - 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes,

2642/2017 - 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1303/2017 - 2º Distrito

Policial de Mogi das Cruzes, 329/2017 - 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Samanta Cristina Ferreira de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

SAMANTA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo apurado, no dia 06 de julho de 2017, em horário incerto, na Rua Professora Lucinda Bastos, cruzamento com a Rua Libéria, S/N, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de traficância: 120 (cento e vinte) porções de crack, peso líquido total de 67.6g (sessenta e sete gramas e seis decigramas), 549 (quinhentos e quarenta e nove) porções de cocaína, peso líquido total de 132.4g (cento e trinta e dois gramas e quatro decigramas), 83 (oitenta e três) porções de maconha, peso líquido total de 251.2g (duzentos e cinquenta e um grama e dois decigramas) e 03 vidros de lança perfume, substâncias entorpecentes que causam

dependência física e química, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve prisão em flagrante, sendo concedida liberdade provisória com medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor da ré, conforme termo de audiência constante dos autos a fls. 86/87.

A denunciada não foi localizada (fls. 117), tendo sido notificada por edital (fls.137) e decretada sua prisão preventiva (fls.133/134).

Após, cumprido o mandado de prisão (fls.149/150), foi pessoalmente notificada (fls.182/186) e apresentou defesa preliminar às fls.216/217.

Por determinação do e. Tribunal de Justiça, foi concedida liberdade provisória com medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor da ré (fls.245).

A denúncia e seu aditamento foram recebidos em 26 de novembro de 2018 (fls. 252).

A ré não foi localizada para citação pessoal (fls.297), sendo citada por edital (fls.314/315). Foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 324).

Após, citada pessoalmente (fls. 346), apresentou resposta à acusação (fls. 350/351).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas, sendo decretada a revelia da acusada (fls. 415/417).

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pleiteou a condenação da acusada nos termos da denúncia e seu aditamento.

A Defesa, por sua vez, alegou, preliminarmente, prova ilegal por inexistir fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição da acusada ou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do redutor (fls. 415/417).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

Preliminarmente, rejeito a alegação defensiva de prova ilegal, uma vez que, conforme revelou a prova colhida em Juízo, a ré foi vista em situação de fundada suspeita e isso permitiu a ação dos policiais em revista pessoal, que prescinde de autorização judicial, em conformidade com o artigo 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

Passo à análise do mérito.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), fotografias (fls. 21/26), laudo de constatação (fls. 403/407), laudo de exame químico-toxicológico, o qual resultou positivo para cocaína e maconha (fls. 408/412), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em Juízo, a testemunha Josué Siqueira Cavalcante Junior, Policial Militar, narrou que estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de entorpecentes. Visualizaram a ré com uma sacola preta na mão. Ao notar a presença da equipe policial, ela dispensou a sacola e evadiu-se. Conseguiram abordá-la e sua parceira efetuou a busca pessoal. O depoente pegou a sacola, que continha vários eppendorfs, drogas embaladas individualmente para a venda. Tinha crack, cocaína, lança perfume, maconha. Indagada, ela disse que era usuária. Não tinha droga com ela, apenas a que dispensou. Não conhecia a ré anteriormente. No local, ponto de venda de entorpecentes, visualizaram apenas a ré. Não se recorda se ela estava com celular, carteira ou qualquer bem pessoal.

No mesmo sentido, a testemunha Fátima Aparecida Dias, Policial Militar, disse que o local é conhecido ponto de venda de drogas. Em serviço de rotina, visualizaram a acusada parada com uma sacola na mão. Com a aproximação policial, ela jogou a sacola e correu. Conseguiram abordá-la e a depoente fez a busca pessoal. Na sacola que ela havia dispensado tinha vários tipos de drogas, eppendorfs, não lembra exatamente quais. Não se recorda se tinha dinheiro na sacola. Em busca pessoal, com ela nada foi encontrado. A ré disse que era viciada em drogas. A depoente já fez

outras prisões no local, é comum a venda de drogas ali. Diz que a acusada, quando avistou a viatura, tentou disfarçar, mas, quando a equipe policial se aproximou, ela jogou a sacola e correu. Ela estava sozinha com a sacola. Não viram ato de comércio. Não se recorda se ela estava com celular, carteira ou qualquer bem pessoal.

A acusada Samanta Cristina Ferreira de Oliveira, ouvida em sede policial, disse que "os fatos narrados pelos policiais militares não são verdadeiros; que é usuária de crack e estava no local para consumir uma pedra com Alan, na hora que estava saindo, a viatura apareceu e abordou a interrogada e Alan; que os policiais militares a disseram que encontraram as drogas na frente da casa de sua amiga Micaela e disseram que era da interrogada; não sabe porque o seu colega Alan foi dispensado pelos policiais militares; que não conhece os policiais militares que efetuarão a sua prisão" (fls. 06).

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade da ré pelo delito em apreço.

Não obstante a negativa da acusada em sede policial, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada. Os dois policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os policiais militares não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar a ré gratuitamente e imputar a ela crime de tamanha gravidade.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Ademais, a fuga da ré denota a consciente e relevante contribuição para o crime e a forte consciência da ilicitude. Neste sentido "A própria fuga do agente de crime, ao perceber a aproximação de policiais ou circunstâncias, indica envolvimento no fato delituoso, pois denota conduta incompatível com aquela que teria pessoa que trouxesse consciência incontaminada, serena e tranqüila." (Prova penal (Doutrina e jurisprudência), Fernando de Almeida Pedrosa, 2ª edição, São Paulo: RT, página 96). Ressalte-se que o fato de ser usuária, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Sendo assim, inviável a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº11.343/06

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO DE JUDICIAL. SÚMULA 282 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Assim, como assentado no acórdão, "para a configuração do delito de tráfico de drogas não é preciso a comprovação da mercancia, bastando que seja praticada uma das condutas contidas no tipo penal". Assim, diante do contexto dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas no exame das provas, concluíram que "a confissão do adolescente V. não teria o condão de afastar a responsabilização criminal da acusada devidamente demonstrada nos autos originários". Incidência da Súmula 7 do STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 1.989.750/PR, relator Ministro

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022, g.n.)

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade da acusada quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

A acusada não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. É cediço que o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial. Através do uso ilegítimo da força, as organizações criminosas instituem formas de domínio sobre os pontos conhecidos de venda de drogas, falando-se, inclusive, em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância, nestes locais, indica inserção do agente nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada. Além disso, a quantidade de droga e forma de acondicionamento é indicativa dessa dedicação às atividades criminosas.

Neste sentido:

(...) na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada (...) nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, (...) a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas (...)) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. AgRg no HC 568062/MS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína e 49 (quarenta e nove) invólucros de maconha, em local conhecido como "ponto" não poderia atuar se já não fosse dedicada ao crime, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que a paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. HC 541065/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda raposo, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020.

A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais". HC 474680/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Encontrando-se devidamente fundamentado o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo Tribunal de origem diante da grande quantidade de droga e pela forma de armazenamento da droga, a desconstituição das premissas fáticas deduzidas no acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1293036/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

Além disso, verifico que a acusada, posta em liberdade nestes autos em 15/11/2018 (fls.249/251), foi novamente presa em flagrante pelo delito de tráfico de entorpecentes no dia 09/05/2019 (fls.402 - processo nº1501133-37.2019.8.26.0616, transitado em julgado em 24/01/2022, conforme pesquisa via SAJ realizada nesta data), o que reforça o seu envolvimento com a prática de crimes, especialmente o tráfico de drogas.

Por oportuno: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes (AgRg no HC n. 553.258/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/6/2020). 2. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC n. 609.887/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a gravidade do delito praticado, bem como a quantidade e natureza das drogas apreendidas. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

Pelos mesmos fundamentos, e pela vedação expressa disposta no artigo 44, "caput", da Lei nº11.343/06, é incabível a substituição da pena privativa aplicada por restritiva de direitos. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré SAMANTA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Poderá a ré apelar em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do

ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo à acusada, defendida pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA